

N. R.G. 3570/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. ssa Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Massimo Meroni	Consigliere rel
dr. ssa Rossella Milone	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3570/2019** promossa in grado d'appello

DA

Pt_1 (C.F. **P.IVA_1**), elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TOPPAN ATTILIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LO PASSO FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RUFFINO FRANCESCO (*C.F._1*) PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; *Controparte_2* (*C.F._2*) PIAZZA SANT'ALESSANDRO, 6 20123 MILANO;

APPELLATA

Oggetto: Franchising

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante *Parte_1*

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in parziale riforma della sentenza n. 7693/2019 del Tribunale di Milano, Sezione V Civile, pronunciata dal Dott. Federico Botta nella causa n. 8159/2016 R.G., pubblicata il 30/07/2019 e notificata il 13/09/2019 e per tutti i motivi esposti in premessa dell'atto di citazione:

NEL MERITO:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dei Contratti di franchising stipulati *inter partes* in data 01/10/2007, dichiarata da *Controparte_1* con comunicazione inviata a *Parte_1* in data 08/01/2015;
- 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di non scarsa importanza di *Controparte_1* alle obbligazioni scaturenti dai Contratti di franchising, stipulati *inter partes* in data 01/10/2007 e pienamente vigenti e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i predetti contratti si sono risolti ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa di *Controparte_1*
- 3) condannare *CP_1* quale incorporante di *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma di € 1.192.303,00, oltre interessi dalla data della domanda fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito di espletanda CTU contabile e commerciale e del presente giudizio o, in subordine, che verrà ritenuta equa e di giustizia, all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.;

4) condannare **CP_1** quale incorporante di **Controparte_1** a pagare a **Parte_1** a titolo di risarcimento del danno emergente subito dall'attrice in conseguenza dei fatti descritti in premessa del presente atto, la somma che verrà ritenuta dovuta all'attrice a tale titolo, all'esito di apposita espletanda CTU commerciale e statistica d'ufficio e del presente giudizio o, in subordine, la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito di valutazione ex art. 1226 c.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

5) ammettere la prova per testimoni sui capitoli n. 1) e n. 2), riportati in premessa della memoria in data 24/11/2016, dimessa da ^{Par} ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati, nonché disporre consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto parimenti dedotto in premessa e sui quesiti riportati nei paragrafi 14) e 15) della predetta memoria;

IN OGNI CASO:

6) condannare **CP_1** in proprio e quale incorporante di **Controparte_1** al pagamento dei compensi e delle spese, oltre rimborso delle spese forfetarie, nella misura del 15% dei compensi, IVA e C.P.A., di entrambi i gradi del presente giudizio.”

Per l'appellata **CP_1 in qualità di **Controparte_1****

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis rejectis*, così giudicare:

in via pregiudiziale e/o preliminare:

- accertare e dichiarare l'appello proposto *ex adverso* inammissibile in quanto non predisposto nelle forme di cui all'art. 342 n. 1) e/o n.

2) c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. dell'appello proposto *ex adverso*, con emissione anche di ordinanza ex art. 348ter c.p.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa;

nel merito:

- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'appello avversario e, comunque, tutte le domande avversarie, in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa, con integrale conferma della sentenza *ex adverso* impugnata n. 7693/2019 del Tribunale di Milano – Sezione V civile - dott. Federico Botta – pubblicata il 30 luglio 2019 e notificata il 13 settembre 2019;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 7693 del Tribunale di Milano pubblicata il 30.7.2019.

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

1) **CP_1** ora incorporata in **CP_1** (odierna appellata) gestiva due supermercati siti l'uno in Azzano S.Paolo e l'altro in Agrate Brianza.

2) **CP_1** e **Controparte_3** (entrambe società controllate e amministrate dalla medesima famiglia **CP_4** che controlla e amministra **CP_1**) gestivano rispettivamente un supermercato a Bellusco e un supermercato a Gorgonzola.

3) **CP_1** ha stipulato con **Org_1** due contratti di franchising in ordine ai due supermercati di Agrate e di Azzano (doc. 2 e 3 appellante) (contratti analoghi a quelli stipulati anche da **CP_1** e da **CP_3**), in cui al punto 2.1 è prevista la pattuizione esplicita della “non esclusiva”, al punto 3.2.5 è disciplinata la fornitura di articoli in offerta promozionale, al punto 3.3.1 è prevista l'indicazione dei prezzi di rivendita consigliati, al punto 4.2.7 è previsto l'obbligo del franchisee di attivare presso il proprio punto vendita le campagne promo – pubblicitarie concordate con il franchisor, al punto 4.3.2 è previsto l'obbligo a carico del franchisee di acquisto presso il franchisor del 60% del fabbisogno, al punto 4.3.3 è prevista la deroga al punto 4.3.2 per l'assortimento concordato, al punto 4.3.4 è prevista la facoltà del franchisor di opporsi ad un determinato fornitore, individuato dal franchisee, al punto 4.3.5 è prevista la facoltà del franchisor di indicare determinati fornitori da cui il franchisee è tenuto a rifornirsi, al punto 4.5.1 è previsto l'obbligo di non concorrenza a carico del franchisee, al punto 8.1 è prevista la durata del rapporto dal 1.10.2007 al 30.9.2017, al punto 14.1 è prevista la clausola risolutiva espressa in favore del franchisor, al punto 4.2 sono previsti i casi di risoluzione previa diffida ad adempiere in favore del franchisor.

4) Il 17.10.2014 l'avv. Lo Passo, per conto di **CP_1**, **CP_1** e **CP_3** lamentando che la trattativa in corso con **Par** al fine di consentire ad altra società, appositamente costituita dal medesimo gruppo **CP_4** (**CP_5** di assumere la gestione dei supermercati di Bellusco e Gorgonzola (facenti parte del gruppo di 53 supermercati da **Par** rilevati in blocco dal gruppo **Org_**), incontrava delle difficoltà ad arrivare alla conclusione per cattiva volontà di **Par** ha evidenziato che l'eventuale gestione diretta da parte di **Par** dei suddetti punti vendita avrebbe provocato effetti pregiudizievoli per le tre società scriventi per via dell'illecita attività concorrenziale che sarebbe stata attuata da **Par** (doc. 5 appellante).

5) Il 23.10.2014 **Par** ha aperto in gestione diretta con l'insegna **Org_1** il supermercato ex **Org_** [... **CP_6** e il 11.11.2014 ha aperto il supermercato di Bellusco.

6) Il 11.11.2014 **Par** ha risposto alla comunicazione di **CP_1** del 17.10.2014, respingendo qualsiasi addebito concorrenziale, in assenza di esclusiva concessa ai franchisee, e spiegando le ragioni del ritardo nella conclusione delle trattative con il gruppo **CP_4** per la concessione in affitto dei supermercati ex **Org_** di Bellusco e Gorgonzola (doc. 6 appellante).

7) Il 8.1.2015 **CP_1** ha comunicato la risoluzione dai due contratti di franchising in corso (e dei contratti accessori) con decorrenza dal 16.1.2015 (doc. 7 appellante), esponendo che:

- . **CP_1** faceva parte del medesimo gruppo di società, di cui facevano parte anche **CP_1** e [...] **Org_3**
- . il 23.10.2014 **Par** aveva aperto un punto di vendita con insegna **Org_1** in Gorgonzola nella stessa piazza commerciale di **CP_3** ;
- . il 20.11.2014 **Par** aveva aperto un punto vendita con insegna **Org_1** in Bellusco nella stessa piazza commerciale di **CP_1** ;
- . nei due punti vendita, gestiti direttamente da **Par** venivano praticati prezzi per un'ampia gamma di prodotti più bassi rispetto a quelli consigliati da **Par** ai franchisee;
- . i franchisee non erano in grado di controllare il fenomeno, in quanto il sistema informativo non era loro accessibile e ciò determinava una distrazione di clientela in loro danno;
- . la clientela si lamentava presso i loro punti vendita per i differenti prezzi praticati e li apostrofava con insulti;
- . in occasione dell'apertura dei nuovi punti vendita di Bellusco e Gorgonzola era stata fatta una campagna promozionale, che aveva escluso i loro punti vendita, e quindi aveva sviato la clientela verso i punti vendita gestiti direttamente da **Par**
- . la promozione era stata integrata con una campagna di sconti speciali (doppio accredito punti sulla tessera fedeltà, comunicazione differenziata sui volantini promozionali, buoni sconti da 5 e 10 euro fino al 31.12.2014);
- . le campagne sconti erano state precedute da altre campagne attuate a mezzo di volantini del servizio **Parte_2** o SMS inviati direttamente alla clientela, senza coinvolgimento del franchisee;
- . in precedenza **Par** aveva promosso altre campagne già contestate (sconto over 60 del 10%, sconto buoni **Org_**, sconto Mondiale), in quanto avevano provocato effetti economico finanziari insostenibili;
- . le iniziative elencate costituivano condotta di concorrenza sleale.

8) Il 13.1.2015 **Par** a riscontro della comunicazione di **CP_1** del 8.1.2015, le ha intimato di continuare ad adempiere ai contratti di franchising in corso tra le parti, manifestando comunque la disponibilità ad un incontro (doc. 8 appellante).

9) Il 20.1.2015 **Par** ha ribadito a **CP_1** che non intendeva liberarla dagli obblighi derivanti dai contratti di franchising e quindi l'intenzione di agire per ottenerne l'adempimento, a fronte del fatto che **CP_1** aveva esposto cartelli con cui annunciava il passaggio alla catena **Org_5** (doc. 11 appellante).

10) Il 23.1.2015 **CP_1** ha ribadito a **Par** che, a causa della concorrenza sleale da questa posta in essere, riteneva risolto il contratto di franchising per grave inadempimento del franchisor (doc. 12 appellante).

3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 11.2.2016, **Parte_1** (appartenente al gruppo **Parte_2**) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano **CP_1** nella sua qualità di incorporante di **Controparte_1** chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione, dichiarata da **CP_1** in data 8.1.2015 di due contratti di franchising (aventi ad oggetto la concessione, in via non esclusiva, della disponibilità della “ **Parte_3** insieme a”, comprensiva di know-how, marchio – successivamente divenuto “ **Parte_2** - e merci) stipulati tra le parti il 1.10.2007, relativi ai punti vendita gestiti da **CP_1** in Agrate Brianza (MI), Via San Francesco, ang. Via Verdi e in Azzano San Paolo (BG), Via del Donatore AVIS-AIDO, accertando e dichiarando, di contro, l'inadempimento di non scarsa importanza di **CP_1** alle obbligazioni scaturenti dai contratti suddetti e, per l'effetto, di dichiararne la risoluzione ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa della convenuta, con condanna di quest'ultima a pagare a **Par** a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente ai dedotti inadempimenti, la somma di € 1.192.303,00, oltre interessi, e, a titolo di risarcimento del danno emergente, la somma ritenuta dovuta all'esito di espletanda CTU o determinata in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c..

Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.6.2016, **CP_1** si è costituita in giudizio, chiedendo, nel merito, in via principale, il rigetto delle domande di **Par** e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento di **Par** alle obbligazioni derivanti dai contratti di franchising e, per l'effetto, dichiararli risolti o, comunque, nulli, nonché il compimento da parte di **Par** di atti di concorrenza sleale a norma degli artt. 2598 c. e, comunque, 2043 c.c., condannando conseguentemente l'attrice al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla convenuta, nella misura da quantificarsi in corso di causa.

Alle udienze del 24/05/2017, del 07/07/2017 e del 19/09/2017 sono stati escussi i testi, richiesti dalle parti e ammessi dal Tribunale: **Testimone_1** **Testimone_2**, **Testimone_3** **Testimone_4** **Testimone_5** **Testimone_6** **Testimone_7** e **Testimone_8**; quindi le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e il Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4) La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

- “1. rigetta le domande formulate da parte attrice;*
- 2. rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta;*
- 3. dichiara compensate per intero tra le parti le spese di lite.”*

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati.

La domanda, formulata in via principale da ^{Par} di accertamento dell'illegittimità della risoluzione dei contratti di affiliazione commerciale stipulati tra le parti il 1/10/2007, dichiarata da [...] ^{Controparte_1} ora fusa per incorporazione in ^{CP_1} con comunicazione inviata a ^{Parte_1} il 8.1.2015 è infondata.

La comunicazione inviata da ^{CP_1} a ^{Par} il 8.1.2015 deve qualificarsi come dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Dal compendio probatorio è emerso che l'apertura dei due punti vendita nella stessa piazza commerciale della convenuta (ed in particolare l'ex supermercato ^{Org_} ora ^{Par} nel Comune di Gorgonzola e il punto vendita acquisito nel Comune di Bellusco, poco distanti da quelli gestiti dalla convenuta) accompagnata dall'offerta di condizioni di vendita più vantaggiose, dall'applicazione di sconti maggiori e da mirate comunicazioni promozionali, abbia portato i clienti storici della convenuta, già fidelizzati al marchio ^{Par} anche attraverso carte di fedeltà, a servirsi presso gli altri punti vendita, con mutamento unilaterale dell'equilibrio economico, perseguito con il contratto, a danno della convenuta, tanto da giustificare la risoluzione.

La risoluzione del contratto, chiesta in via riconvenzionale da ^{CP_1}, è quindi fondata per il fatto che ^{Par} ha violato la regola di esecuzione del contratto secondo buona fede, dato che:

1) ^{Par} ha aperto due nuovi punti vendita nella stessa piazza commerciale di ^{CP_1}; il fatto che il contratto non preveda l'esclusiva in favore dell'affiliato è irrilevante, in quanto nel contratto di franchising "*un minimo grado di protezione territoriale*" dell'affiliato è indispensabile, altrimenti l'affiliato non si assumerebbe l'onere di sostenere ingenti spese per integrarsi nella rete, e lo schema negoziale rischierebbe di essere minato in radice, sotto il profilo causale; pertanto si ha una condotta potenzialmente abusiva, quando si riducano le capacità di profitto dell'affiliato, massimizzando quelle dell'affiliante, specialmente allorquando venga posta in essere una concorrenza *intra-brand* ed il nuovo rivenditore sia lo stesso franchisor; nel caso in esame, il grado di affidamento dell'affiliata in ordine all'ambito territoriale, in cui operare senza concorrenza *intra-brand*, si era consolidato per diversi anni (posto che il contratto in corso era stato stipulato nel 2007).

2) Nei nuovi punti vendita ^{Par} ha applicato prezzi, in conseguenza di apposita campagna promozionale pubblicizzata, più bassi rispetto a quelli di ^{CP_1}; questa condotta ha inciso sull'obbligo di corretta e leale collaborazione, che impone all'affiliante di non sviare gli affari dell'affiliato verso altri affiliati, tenuto conto che ^{CP_1} non avrebbe potuto a sua volta ridurre i prezzi, sia per mancanza di margine di guadagno, sia perché soggetta a prezzi imposti dall'affiliata, sia perché era previsto un obbligo di approvvigionamento presso ^{Par} pari al 60%.

3) In conseguenza delle suddette condotte i clienti storici di ^{CP_1}, fidelizzati dalla carta fedeltà, sono stati indotti a servirsi dei nuovi punti vendita, dato che è plausibile ritenere che il malcontento manifestato dalla clientela, che vedeva applicati per i medesimi articoli prezzi più alti rispetto agli altri negozi gestiti

direttamente dall'affiliante, abbia provocato uno spostamento della clientela storica verso gli altri negozi della stessa catena non troppo distanti.

La domanda riconvenzionale formulata da CP_1 di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla concorrenza sleale, non può essere accolta.

Dato che la parte, che assuma di avere subito un danno, ha l'onere di provarne in maniera rigorosa l'esistenza, la sua derivazione causale e il suo concreto ammontare, salvo quanto previsto dall'art. 1226 c.c., nella fattispecie in esame i danni lamentati (lesione all'immagine, sviamento o rischio di sviamento della clientela, sottrazione di fette di mercato) sono da ritenersi insufficientemente allegati e provati sia sotto il profilo del nesso causale sia sotto il profilo del *quantum debeatur*.

5) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale Parte_1 ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

Primo motivo d'appello: il Tribunale ha errato nella ricostruzione dei fatti di causa, determinati da una valutazione incompleta e superficiale del compendio probatorio, che lo hanno condotto ad accertare un'insussistente violazione, da parte di Par degli obblighi di buona fede nell'esecuzione dei contratti di franchising, stipulati tra le parti.

In primo luogo, non trova alcun riscontro nel compendio probatorio la circostanza che Par avrebbe aperto i nuovi punti vendita, ex Org-, di Gorgonzola e Bellusco nella “stessa piazza commerciale” e “poco distanti” da quello gestito da CP_1 essendo, al contrario, rimasta del tutto indimostrata proprio l'esistenza di un rapporto di “concorrenza” tra imprenditori.

In secondo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo la quale Par avrebbe posto in essere, a seguito dell'apertura dei punti vendita ex Org- “*offerta[e] di condizioni di vendita più vantaggiose, [...] applicazione di sconti maggiori e [...] mirate comunicazioni promozionali*”, non tiene conto delle circostanze, tutte incontestate e risultanti dalla documentazione prodotta, nelle quali dette condotte sono state poste in essere e delle relative modalità e finalità, e cioè che le speciali promozioni incriminate sono state poste in essere da Par solo per un limitato periodo di (al massimo) due settimane, in occasione dell'apertura dei nuovi punti vendita di Gorgonzola Parte_4 e all'unico scopo di attirare la clientela ex Org- (e non certo quella, già Parte_2 di CP_1 nei nuovi supermercati a marchio Parte_2).

In terzo luogo, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata e poi smentito dallo stesso Tribunale, non risulta affatto dal compendio probatorio che le condotte, poste in essere da Par e sopra descritte (apertura di due nuovi punti vendita di Parte_5 e offerte promozionali in occasione delle nuove aperture), avessero “*portato i clienti storici della convenuta, già fidelizzati al marchio Par anche attraverso carte di fedeltà, a servirsi presso gli altri punti vendita*”.

Secondo motivo d'appello: le statuizioni del Tribunale sono viziate da errori di diritto, sia nella parte in cui, in violazione delle disposizioni della Legge Franchising, mirano a riconoscere, in sostanza, un'esclusiva territoriale a favore del franchisee in assenza della relativa e necessaria pattuizione contrattuale, sia nelle parte in cui, in violazione degli stessi richiamati principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, il Tribunale non ha affatto verificato né che il comportamento tenuto da ^{Par} abbia provocato alcun concreto pregiudizio a CP_1 né che l'eventuale astensione dal predetto comportamento non avrebbe comportato un apprezzabile sacrificio a carico di ^{Par}

Terzo motivo d'appello: il Tribunale, rispetto al rilievo di ^{Par} secondo il quale, con il mero invio della comunicazione dell'8.1.2015, CP_1 non avrebbe potuto ritenersi legittimamente sciolta dai propri obblighi contrattuali per mezzo della dichiarata "risoluzione" del Contratto, non essendosi verificata alcuna causa di risoluzione di diritto del Contratto medesimo, non essendo detta comunicazione stata preceduta da alcuna diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., né essendosi verificata nessuna delle altre ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ha statuito che:

. la comunicazione dell'8.1.2015 dovesse qualificarsi come dichiarazione di volersi avvalere di una "clausola risolutiva espressa";

. CP_1 dichiarando la risoluzione del contratto, si è legittimamente avvalsa di tale clausola, essendo stata accertata dal Tribunale la violazione, da parte di ^{Par} dell'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del Contratto.

Quarto motivo d'appello: come conseguenza dell'illegittimità della risoluzione dei contratti, dichiarata da CP_1 e dell'inadempimento della controparte (con conseguente risoluzione dei medesimi contratti per fatto e colpa dell'appellata) agli obblighi richiamati nei paragrafi precedenti, CP_1 dovrà essere condannata a risarcire a ^{Par} i danni patrimoniali, conseguenti all'avversario inadempimento e alla risoluzione anzitempo del Contratto per fatto esclusivamente imputabile all'appellata, sia per quanto riguarda il lucro cessante sia per quanto riguarda il danno emergente.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale CP_1 nella sua qualità di incorporante di Controparte_1 ha chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

In ordine al primo motivo di appello: gli asseriti errori di fatto contenuti nella Sentenza.

a) Il "rapporto di concorrenza" e contiguità ravvisato tra i Punti Vendita Parte_6 e i punti vendita del CP_7

- l'affidamento riposto dalle affiliate su un determinato assetto della rete distributiva, così come loro prospettato in sede di stipula del contratto di franchising, sussiste ed è meritevole di tutela per effetto della normativa di settore, indipendentemente dalla previsione di un'esclusiva territoriale;

- la contiguità di tutti i punti vendita del CP_7 ivi compreso quello CP_1, rispetto ai Punti Vendita Litigiosi, gestiti direttamente da Par risulta accertata, anche a prescindere dal rilievo che, una volta intaccato il rapporto fiduciario fra *franchisor* e *franchisee* rispetto anche ad uno soltanto dei punti vendita, viene compromesso il rapporto rispetto a tutti i punti vendita in franchising gestiti fra le medesime parti sostanziali.

b) Le accertate e dichiarate condotte illegittime, contrarie al contratto e a buona fede, poste in essere dall'affiliante a danno delle affiliate (per un asserito limitato periodo di tempo):

- Par ha confessato di aver svolto tutte le attività concorrenziali sleali, alla stessa imputate e richiamate nella sentenza impugnata;

- in ordine alla durata, asseritamente temporalmente limitata, di tale concorrenza sleale, a prescindere dalla sua irrilevanza (in quanto anche “solo” due settimane sarebbero rilevanti, specie per quanto riguarda la lesione del rapporto fiduciario fra le parti), si tratta di una mera “dichiarazione di parte”, smentita sia dai documenti prodotti sia dai testimoni escussi, che hanno confermato che le promozioni si sono protratte per oltre due mesi.

c) L'accertato sviamento della clientela ai danni del CP_7 così come confermato e risultante dalle prove testimoniali:

- i testimoni escussi in primo grado hanno confermato, non solo, lo sviamento della clientela, ma anche, il malcontento generatosi tra i consumatori per effetto delle differenze di prezzo e delle campagne promozionali, praticate da Par a vantaggio dei soli Punti Vendita Litigiosi, con conseguente pregiudizio dell'immagine commerciale della convenuta.

d) Gli accertamenti in merito alla sussistenza di prezzi imposti da parte del franchisor, dell'obbligo di approvvigionamento nella misura del 60% in capo all'affiliata, dell'obbligo di concordare il materiale pubblicitario:

- le statuizioni del Tribunale trovano tutte fondamento nelle risultanze probatorie, da cui emerge:

. l'esistenza di un sistema informatico gestito da Par attraverso il quale venivano trasmessi i prezzi “consigliati” alle affiliate;

. la numerosità delle variazioni dei prezzi indicate quotidianamente e nottetempo da Par su tutti i prodotti, ivi compresi quelli a marchio Parte_2, prodotti sui quali, più frequentemente di altri, per evidenti ragioni di promozione del marchio, venivano praticati sconti da parte di Par

. l'impossibilità per i vari *franchisees* di verificare, tramite il sistema gestionale Par i prezzi praticati dagli altri affiliati e, segnatamente, l'impossibilità per le società del CP_7 di controllare i prezzi praticati nei punti vendita ex Org_, gestiti direttamente da Par trattandosi di c.d. “sistema chiuso”;

- non è vero che le affiliate potevano rifornirsi per il 100% da terzi, dandone comunicazione a Parte_2 a partire dal superamento della soglia del 60%; è vero invece che le affiliate avevano l'obbligo di

rifornirsi per almeno il 60% dall'affiliante e che solo per la restante quota del 40% avevano facoltà di rifornirsi da terzi;

questo dato è confermato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dal doc. 43 (cioè le lettere che indicano tutti gli sconti di fine anno, di cui le affiliate avrebbero potuto beneficiare), nel quale lo sconto "incondizionato" del 3,75% è riconosciuto al conseguimento della soglia minima di acquisto del 60%;

- se è vero che le affiliate potevano svincolarsi dalle iniziative pubblicitarie e promozionali e quindi non aderire alle medesime, è anche vero che la mancata adesione avrebbe avuto effetti disastrosi per le affiliate medesime, perché la clientela, edotta delle promozioni, ne avrebbe comunque preteso (giustamente) l'applicazione, pena la rinuncia, anche in via definitiva, a rivolgersi per i propri acquisti presso quei punti vendita.

In ordine al secondo motivo di appello: gli asseriti errori di diritto contenuti nella Sentenza.

a) La statuizione del Tribunale che impone un certo grado di protezione territoriale nell'ambito del contratto di franchising:

- l'interpretazione di ^{Par} degli accordi tra le parti e della L. n. 129/2004 consentirebbe all'affiliante di danneggiare impunemente l'affiliato, eliminandolo dal mercato, e finirebbe altresì per negare la ragione stessa della causa di collaborazione sottesa al contratto di franchising;

- l'obbligo di protezione e collaborazione tra affiliante e affiliato include innanzi tutto l'obbligo di astensione di qualsiasi comportamento contrario alla correttezza imprenditoriale da parte del franchisor;

- la mancanza di una clausola che attribuisca all'affiliato un diritto di esclusiva territoriale non consente per ciò solo all'affiliante di svolgere sullo stesso territorio, in cui opera l'affiliato, qualsiasi attività imprenditoriale in modo concorrenziale e non coordinata, idonea, quindi, a sviare la clientela storica di quest'ultimo.

b) La gravità della condotta posta in essere da ^{Par} e delle sue conseguenze:

- non è vero che l'acquisto dei 53 punti vendita ex ^{Org} fosse un "acquisto in blocco";

- l'esatta conoscenza da parte delle affiliate dei punti vendita, afferenti alla stessa catena distributiva di ^{Par} presenti sul territorio, era circostanza determinante del consenso per la stipulazione dei contratti di franchising;

- ^{Par} era consapevole delle problematiche concorrenziali, che si sarebbero determinate a seguito dell'acquisto dei due punti vendita ex ^{Organizzazione_6}, tanto che nel settembre 2014, ha proposto al ^{CP_7} l'affitto d'azienda dei citati punti vendita, così da non avere una concorrenza interna alla medesima catena ai danni del suddetto storico affiliato, ^{CP_7}

- successivamente all'apertura dei due Punti Vendita ^{Parte_6} malgrado il ^{CP_7} si fosse prontamente lamentato delle politiche concorrenziali, poste in essere da ^{Par} questa non è mai entrata nel merito delle contestazioni sollevate dalle affiliate, rifiutandosi di condividere una politica commerciale,

che non fosse dannosa per i punti vendita **Org_1** del **CP_7** preferendo quindi anteporre la sua volontà e i suoi interessi a qualsiasi altra questione, per poter sviare la clientela storica delle affiliate a favore dei punti vendita gestiti direttamente;

- **CP_1** e le altre affiliate erano costrette a subire gli effetti dannosi del comportamento concorrenziale di **Par** in quanto, contrariamente a quanto affermato da controparte, non avevano alcuna possibilità di determinare i prezzi in uscita praticati alla clientela, che erano imposti da **Par**

- i contratti per cui è causa, dopo un rapporto di circa 20 anni, sarebbero naturalmente scaduti nel giro di meno di due anni, con il 1.10.2017 e, quindi, **Par** una volta acquisita la clientela storica dei punti vendita delle affiliate del gruppo **CP_4** tramite sviamento a favore dei punti vendita ex **Org** gestiti direttamente, avrebbe potuto non rinnovare con le suddette i contratti di affiliazione, essendosi così in buona parte appropriata del loro avviamento.

In ordine al terzo motivo di appello: la clausola risolutiva espressa.

Nel caso di specie trova applicazione la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 14 del contratto di franchising ("RISOLUZIONE"), ai sensi della quale si determina la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto, in caso di: "*art. 14.1.1. ...inadempimento, anche parziale, ad uno o più degli obblighi previsti dagli articoli 3 (impegni del **Parte_7**)*", posto che risultano violati gli artt. 3.1.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1, 9 dei contratti di *franchising* che impongono specifici obblighi di informazione, assistenza, somministrazione e parità di trattamento nei confronti dei *franchisees*, tutti violati da controparte.

In ordine al quarto motivo di appello: il danno.

Il Tribunale ha evidenziato l'infondatezza, per carenza di prova, della domanda risarcitoria relativa al c.d. danno emergente (correttamente qualificato come danno non patrimoniale in quanto riferito "all'immagine di **Par**").

La determinazione del danno da lucro cessante, operata da **Par** non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni e cioè:

. perché il dato di partenza, cioè il fatturato considerato, ovvero quello di tutte le attività svolte da **Par** non è corretto, in quanto comprende attività che non rilevano nel caso in esame;

. perché il fattore moltiplicatore, e quindi il margine indicato, non tiene conto del costo dei servizi e dei contributi a favore dei *franchisees* e del relativo effetto sui calcoli dei margini.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

Prima questione: sussistenza e rilevanza dei fatti, lamentati da **CP_1 come inadempimento di **Part****

1) Sussistenza di un rapporto concorrenziale tra i punti vendita, aperti da ^{Par} e dalla stessa direttamente gestiti in Bellusco e Gorgonzola, e il punto vendita gestito da ^{CP_1} in Agrate.

E' incontestato che ^{Controparte_1} che gestisce i supermercati di Agrate Brianza e di Azzano S.Paolo, ^{CP_1} che gestisce il supermercato di Bellusco, e ^{Controparte_3} che gestisce il supermercato di Gorgonzola sono controllate e amministrate dalla medesima "famiglia" ^{CP_4}.

L'appellata sostiene, pertanto, che le tre società menzionate costituiscono un soggetto economico unitario e quindi che i contratti di franchising, dalle stesse conclusi con ^{Par} sono tra loro inscindibili, in quanto:

a) Il 17.11.2006 tra ^{Par} da un lato, e ^{CP_1}, ^{CP_1} e ^{CP_3}, dall'altro, è stato concluso un accordo, in forza del quale, da un lato, ^{Par} si è obbligata a concedere in gestione (mediante subentro nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ovvero mediante affitto di ramo d'azienda, in entrambi i casi unitamente alla cessione del relativo contratto di locazione) ad una società del medesimo Gruppo il nuovo supermercato di Agrate, in fase di apertura, (poi effettivamente acquisito in gestione da ^{CP_1}) e, dall'altro lato, le tre suddette società si sono obbligate a restare affiliate (sia con il nuovo esercizio di Agrate, sia con i preesistenti esercizi di Bellusco, di Gorgonzola, di ^{Pt_8} e di Azzano S.Paolo), con contratto di franchising, a ^{Par} per un periodo di dieci anni (doc. 3 bis appellata);

b) il 1.10.2007, in esecuzione del suddetto accordo, tra ^{Par} da un lato, e ^{CP_1}, ^{CP_1} e ^{Org_3}, dall'altro, sono stati conclusi distinti contratti di franchising (uni dei quali relativo al nuovo esercizio di Agrate), che prevedevano la durata decennale dal 1.10.2007 al 30.9.2017, nella sostanza tra loro identici (doc. 6 e 6 bis appellata e doc. 2 e 3 appellante);

c) ^{Par} in vista della conclusione di un accordo per concedere la gestione dei due nuovi supermercati ex ^{Org_} di ^{Parte_5}, ha condotto le trattative con il gruppo ^{CP_4} (doc. 14, 15, 16 e 17 appellata);

d) nel periodo precedente alla conclusione dei contratti di franchising sub. b) (quindi prima del 2007), ai fini della concessione dello sconto di fine anno commisurato al fatturato, per valutare il raggiungimento della soglia minima ^{Par} comunicava che si sarebbe valutato il fatturato complessivo delle tre società (doc. 25, 26 appellata);

e) nel periodo successivo alla conclusione dei contratti di franchising sub. b) (quindi dopo il 2007), ai fini della concessione degli sconti di fine anno e dell'individuazione del "margine garantito" ^{Par} ha precisato che gli obiettivi di fedeltà si intendevano "di gruppo" (ricomprendendo nel Gruppo ^{CP_1}, ^{CP_1} e ^{CP_3}) (doc. 33, 34 appellata).

L'opinione della Corte d'Appello.

Dai fatti esposti, in particolare da quelli elencati sub. a), sub. d) e sub. e), emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto da ^{Par} le parti hanno ritenuto, sia nel momento in cui sono stati conclusi i contratti di franchising, nella medesima data e con il medesimo contenuto e in esecuzione dell'accordo unitario del 17.11.2006, sia nel momento in cui i contratti hanno avuto esecuzione, che il

rapporto di franchising intercorrente tra ^{Par} da un lato, e CP_1 , CP_1 e CP_3 , dall'altro, era unico e inscindibile.

D'altro canto si rileva che, comunque, la distanza tra i nuovi supermercati aperti da ^{Par} in Bellusco e Gorgonzola e il supermercato gestito da Parte_9 è inferiore a 10 km e, pertanto, tenuto conto che mediamente il cliente del supermercato (soprattutto per la vendita di generi alimentari e di prodotti per la casa) utilizza l'autovettura per l'effettuazione degli acquisti, è evidente che una distanza così limitata tra i suddetti punti vendita non può certo costituire un significativo ostacolo per l'instaurazione di un rapporto di concorrenza tra gli stessi, che devono quindi essere considerati, in ogni caso, come operanti nella medesima piazza commerciale.

In conclusione quindi la Corte ritiene che effettivamente tra i punti vendita, ex ^{Org}, aperti da ^{Par} in Bellusco e in Gorgonzola e il punto vendita gestito da Parte_9 sussisteva un rapporto di concorrenzialità, sia per il fatto che anche il supermercato di Agrate si trovava nella medesima piazza commerciale degli altri due, sia per il fatto che tra ^{Par} e il gruppo societario, costituito da CP_1 , CP_1 e CP_3 , intercorreva un rapporto di franchising unitario e pertanto la concorrenza svolta dai due nuovi supermercati ex ^{Org} di Bellusco e di Gorgonzola, che interferiva indubitabilmente, quanto meno, con l'attività svolta da CP_1 in Bellusco e da CP_3 in Gorgonzola, incideva anche sull'attività di CP_1 , in quanto facente parte del medesimo gruppo.

2) Sussistenza del carattere contrario alla buona fede della politica dei prezzi di vendita ribassati attuata da ^{Part} nei due supermercati, ex ^{Org}, di Bellusco e di Gorgonzola, che operavano nella medesima piazza commerciale dei supermercati di CP_1 CP_1 e CP_8

[...] , come detto, con la comunicazione del 8.1.2015, ha dichiarato risolto il contratto di franchising del 1.10.2007 a far data dal 16.1.2015 e, nel presente giudizio, ha sostenuto che ^{Par} era inadempiente, in quanto erano risultate provate le seguenti circostanze:

- . ^{Par} subito dopo l'apertura dei due supermercati in questione, aveva praticato in tali punti vendita dei prezzi più bassi rispetto a quelli dalla stessa ^{Par} indicati all'affiliata (circostanza che risulterebbe dagli scontrini di cui al doc. 29 appellante);

- . CP_1 non aveva la possibilità di abbassare i prezzi praticati, in quanto doveva rispettare quelli indicati dall'affiliante (e comunque su quelli forniti da terzi, l'abbassamento del prezzo avrebbe determinato una perdita, in quanto il prezzo d'acquisto era determinato da ^{Par} ;

- . a decorrere dal 23.10.2014, ^{Par} aveva riservato solo ai titolari di carta Payback (cioè la tessera fedeltà per i clienti ^{Par} , rilasciata nei nuovi punti vendita ^{Par} i buoni sconto di € 5 e di € 10, validi fino al 31.12.2014 (circostanza che risulterebbe dai doc. 39 e 40 appellata);

- . ^{Par} aveva attribuito il raddoppio dei punti spesa esclusivamente agli acquisti effettuati presso i nuovi punti vendita ^{Par} (circostanza che risulterebbe dal doc. 41 appellata);

. ^{Par} aveva distribuito volantini, in cui erano pubblicizzati, per singoli prodotti, sconti più elevati per quelli venduti nei nuovi supermercati ^{Par} rispetto a quelli venduti presso CP_1 (circostanza che risulterebbe dal doc. 28 appellata);

. ^{Par} aveva affisso cartelli pubblicitari davanti ai supermercati del gruppo CP_4 che pubblicizzavano sconti particolari applicati nei nuovi punti vendita ^{Par} (circostanza che risulterebbe dal doc. 30 appellata);

. ^{Par} aveva inviato SMS ai clienti del gruppo CP_4 (il cui numero telefonico era stato acquisito dalle carte fedeltà Payback), per pubblicizzare sconti e promozioni praticati solo presso i nuovi punti vendita ^{Par}

Con riguardo ai suddetti addebiti, ^{Par} ha sostenuto che:

. le promozioni e gli sconti, effettivamente attuati, hanno avuto una durata limitata a due settimane ed erano finalizzati a indurre i clienti già ^{Org_} a continuare ad approvvigionarsi presso i medesimi punti vendita di Bellusco e Gorgonzola passati a ^{Par} (circostanza che risulterebbe dai doc. 22, 23, 24, 25 appellante);

. la temporaneità della speciale promozione per i due nuovi punti vendita, giustificata dalla nuova apertura, è confermata dalla comunicazione inviata da ^{Par} il 23.12.2014, a cui però CP_1 non ha aderito (circostanza che risulterebbe dal doc. 26 appellante);

. dagli scontrini prodotti in giudizio da CP_1, di difficile lettura, in quanto si riferiscono a un gran numero di prodotti non direttamente comparabili tra loro, emerge comunque che le differenze sono minime e che, se è vero che per alcuni prodotti i prezzi sono più bassi quelli praticati nei supermercati Org_7, per altri prodotti è vero invece il contrario.

L'opinione della Corte d'Appello

A) L'insussistenza della clausola risolutiva espressa.

Innanzitutto si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la comunicazione di CP_1 del 8.1.2015 non può qualificarsi come dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., tenuto conto che in questa comunicazione non viene neppure indicata quale sia la clausola contrattuale che consentirebbe la risoluzione del contratto né il Tribunale l'ha individuata.

In realtà nel contratto di franchising è bensì prevista, all'art. 14, una clausola risolutiva espressa, ma esclusivamente in favore del franchisor e non già in favore del franchisee, come risulta chiaramente dal tenore letterale della stessa *“14.1 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi qui appresso previste, il Parte_7 potrà risolvere automaticamente, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 c.c., l'accordo mediante l'invio al CP_9 di comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R. La risoluzione avrà luogo di diritto ed avrà effetto dal momento in cui l'altra parte avrà ricevuto la comunicazione di risoluzione”*.

A fronte di tale chiarissimo e inequivoco tenore letterale dell'art. 14.1, il fatto che il contratto enumeri, nei successivi punti 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5 e 14.1.16, tra i fatti che consentono la

risoluzione, oltre a sei fatti che prevedono obblighi dei franchisee, anche, nel primo periodo del punto 14.1.1., “*l’inadempimento, anche parziale, ad uno o più degli obblighi previsti agli art. 3 (Impegni del Parte_7)*”, qualora non sia un mero refuso (come sostenuto da ^{Par}, tale indicazione non può che riferirsi agli obblighi che, pur previsti nell’art. 3 (rubricato “Impegni del Parte_7 ”), sono però obblighi o oneri posti a carico del franchisee (quali, ed esempio, l’obbligo dell’uso da parte del franchisee delle insegne, logotipi, emblemi, segni distintivi secondo le modalità stabilite, l’obbligo di pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al punto 3.1.3, l’obbligo di restituzione al franchisor di bancali, rolls e cassette utilizzate per la consegna della merce, l’obbligo di conformarsi al progetto di lay out e di immagine del punto vendita).

In ogni caso nessuno degli obblighi, esplicitati nell’art. 3 del contratto a carico del franchisor, risultano violati; in particolare non risultano violati quelli menzionati dall’appellata (e richiamati dal Tribunale), cioè quelli previsti agli art. 3.1.2 lett. c), 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3.1 e 9.

L’art. 3.1.2 lett. c) si limita a prevedere che il franchisor debba fornire al franchisee “*il programma delle campagne per la promozione delle vendite e la valorizzazione dell’immagine della rete*”; è evidente che tale obbligo riguarda le campagne promozionali che interessano l’affiliato, mentre, per i motivi che saranno esposti successivamente, le campagne promozionali oggetto della presente controversia legittimamente non lo riguardavano.

L’art. 3.2.4 prevede l’obbligo a carico del franchisor di comunicare al franchisee “*le variazioni ai quantitativi delle merci somministrate ai relativi prezzi di cessione indicati nei listini*”, variazioni che potevano essere discrezionalmente apportate in qualsiasi momento dal franchisor; non si comprende quale sia la violazione imputata al franchisor in ordine a questa disposizione, posto che l’appellata non ha mai allegato la mancata comunicazione delle variazioni dei quantitativi di merce somministrate o dei relativi prezzi.

L’art. 3.2.5 prevede la facoltà per il franchisor “*di indicare i quantitativi minimi e massimi ordinabili per la somministrazione di articoli in offerta speciale, a fronte di particolari condizioni di mercato*”; anche in tal caso non si comprende quale sia la violazione imputata al franchisor, posto che l’appellata non ha mai allegato l’assenza di indicazione dei quantitativi minimi e massimi ordinabili.

L’art. 3.2.6 prevede che il franchisor “*garantisce che le merci saranno le stesso ugualmente fornite agli altri punti vendita della rete commerciale nell’area in cui opera il franchisee*”; anche in tal caso non si comprende quale sia la violazione imputata al franchisor, posto che l’appellata non ha mai allegato la mancata fornitura di merce uguale a quella fornita agli altri punti vendita della sua area.

L’art. 3.3.1 prevede che il franchisor “*fornisce al franchisee il listino dei prezzi di vendita consigliati*”; anche in tal caso non si comprende quale sia la violazione imputata al franchisor, posto che l’appellata non ha mai allegato la mancata comunicazione dei prezzi consigliati.

L’art. 9 (anch’esso richiamato dall’art. 14.1.1 quale ipotesi che legittima il franchisor, ma non certo il franchisee, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa) concerne gli obblighi di comunicazione a carico del franchisee per il caso di mutamento della compagine sociale, degli amministratori, della forma

giuridica, della sede; pertanto è del tutto incomprensibile quale sia la sua rilevanza nella fattispecie in esame.

In conclusione nessuna delle clausole, sopra menzionate, né esaminate singolarmente né valutate congiuntamente, prevede, di per sé, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata:

- . il divieto per il franchisor di realizzare campagne promozionali o offerte speciali differenziate tra punti di vendita operanti nella medesima area;

- . il divieto per il franchisor di consigliare prezzi differenziati all'interno della rete distributiva (e quindi di fornire listini prezzi differenziati) e men che meno l'obbligo a carico di taluni affiliati di praticare prezzi più elevati rispetto ad altri;

- . il divieto di praticare prezzi di fornitura della merce differenziati tra i diversi punti vendita.

B) La rilevanza, in sé e per sé, dell'attività concorrenziale svolta dai punti vendita di Bellusco e Gorgonzola. Org_7

Innanzitutto si rileva che nei contratti di franchising, oggetto della controversia, era esplicitamente previsto all'art. 2.1 che la concessione all'affiliato “della formula ^{Par} “*insieme a*”, *comprensiva di know-how, marchio e merci*” avveniva “*non in esclusiva*”.

D'altro canto l'art. 3 n. 4 lett. c) L. 129/2004 esplicitamente prevede solo come “eventuale” il patto di esclusiva territoriale nel contratto di franchising.

Pertanto qualora il contratto preveda l'esclusiva territoriale, al franchisor è vietato di stipulare altri contratti di franchising con altri franchisee, operanti nel medesimo territorio già concesso ad altro contraente, e, a maggior ragione, gli è vietato svolgere direttamente la medesima attività svolta dall'affiliato; qualora invece il contratto non preveda l'esclusiva territoriale, al franchisor è consentito sia stipulare altri contratti di franchising sia svolgere direttamente attività nel medesimo territorio in cui opera l'affiliato.

La Corte non ritiene condivisibile quanto affermato dal Tribunale, secondo cui, anche in assenza del patto di esclusiva territoriale, nel contratto di franchising l'affiliante deve assicurare “*un minimo grado di protezione territoriale*” all'affiliato, altrimenti questi non si assumerebbe l'onere di sostenere ingenti spese per integrarsi nella rete e lo schema negoziale rischierebbe di essere minato in radice, sotto il profilo causale.

Infatti, a prescindere dal fatto che, nella fattispecie in esame, il corrispettivo a carico dell'affiliato, previsto per integrarsi nella rete commerciale di ^{Par} pari a € 3.000 annui, non pare proprio costituire quell'ingente spesa, che dovrebbe giustificare il diritto al “*minimo grado di protezione territoriale*” e, a prescindere, altresì, che non è dato comprendere da dove abbia origine il diritto menzionato dal Tribunale, qualora si aderisse alla tesi da questo prospettata verrebbe, inammissibilmente e ingiustificatamente, del tutto eliminata qualunque differenza tra il contratto di franchising con patto di esclusiva territoriale in favore dell'affiliato e il contratto di franchising privo del patto di esclusiva, differenza ritenuta invece legittima proprio dalla L. 129/2004.

In entrambe le situazioni infatti, aderendo alla tesi propugnata dal Tribunale, al franchisor sarebbe comunque vietato di svolgere, nel territorio in cui opera l'affiliato, attività in concorrenza con quello o direttamente o per il tramite di altro affiliato; nel caso in cui fosse stata pattuita l'esclusiva, il divieto deriverebbe dal patto, mentre, nel caso in cui non fosse stata pattuita l'esclusiva, il divieto deriverebbe dal generale obbligo di assicurare *“un minimo grado di protezione territoriale”*.

In conclusione, pertanto, la Corte ritiene che il fatto che ^{Par} abbia aperto due punti vendita in Bellusco e in Gorgonzola, che, pacificamente, svolgono attività in concorrenza con quella svolta nel medesimo territorio dalle società appartenenti al gruppo sociale, di cui fa parte anche CP_1, non costituisce, di per sé considerato, una violazione degli obblighi derivanti dai contratti di franchising, intercorsi tra le parti.

C) Il carattere contrario al principio di esecuzione di buona fede della politica di applicazione di prezzi ribassati e di campagne promozionali differenziate.

Con il contratto di franchising, senza patto di esclusiva territoriale, tenuto conto anche della disciplina di tale contratto contenuta nella L. 129/2004, l'affiliato viene a trovarsi inserito in una rete commerciale, nell'ambito della quale all'affiliante, in virtù delle clausole contenute nel contratto, è attribuita la possibilità di condizionare le scelte imprenditoriali operative dei singoli affiliati, da cui dipende la possibilità per costoro di conseguire o meno profitti dall'attività svolta.

Pertanto deve ritenersi che, anche in assenza di specifiche clausole contrattuali in tal senso, secondo il principio di esecuzione di buona fede, i singoli affiliati, che svolgono la medesima attività imprenditoriale, in quanto facenti parte della medesima rete commerciale attuata e diretta dall'affiliante, devono essere posti in grado dall'affiliante, proprio perché non usufruiscono del vantaggio derivante dallo svolgimento in esclusiva dell'attività oggetto del franchising in una determinata area ma devono invece subire la concorrenza nella medesima area di altri affiliati, di svolgere l'attività in questione a condizioni uguali a quella di tutti gli affiliati, operanti nella medesima area; pertanto deve ritenersi che, secondo il principio di esecuzione di buona fede, l'affiliante è obbligato a consentire a tutti gli affiliati, operanti nel medesimo territorio, che si trovino nelle medesime condizioni di fatto, di usufruire dei medesimi servizi, di rifornirsi delle medesime merci e di praticare i medesimi prezzi; in caso contrario, l'affiliante provocherebbe una distorsione nella concorrenza tra i diversi affiliati, determinata non dalle differenti capacità imprenditoriali degli stessi, cosa che sarebbe ovviamente del tutto legittima, ma determinata dalle differenti condizioni di partenza, a cui gli stessi sarebbero ingiustificatamente sottoposti.

Ovviamente il medesimo principio è applicabile anche nel caso in cui la concorrenza nella medesima area è posta in essere direttamente dal franchisor, che ritenga di svolgere in proprio la medesima attività svolta in franchising dall'affiliato.

D) La condotta tenuta da ^{Part} accertata nel presente giudizio.

a) In primo luogo, dai documenti prodotti in giudizio, dai fatti allegati delle parti stesse e dalle testimonianze assunte risulta provato che, in occasione delle aperture dei punti vendita ex ^{Org} di

Bellusco e di Gorgonzola, ^{Par} ha posto in essere campagne promozionali, mediante sconti sui prezzi praticati, ampiamente pubblicizzate, riservate, in via esclusiva, ai suddetti punti vendita.

La circostanza è esplicitamente ammessa anche dall'appellante ed inoltre emerge chiaramente dai documenti n. 28, 30, 39, 40, 41 prodotti da ^{CP_1} e n. 22,23, 24 e 25 prodotti da ^{Par}

Non risulta invece in alcun modo provato che la campagna promozionale in questione si sia protratta oltre le due settimane dalla data di apertura dei nuovi supermercati, indicate da ^{Par}

Anzi dai documenti prodotti si evince che tale campagna promozionale ha effettivamente avuto la durata indicata da ^{Par} infatti:

. il doc. 22 appellante e il doc. 28 appellata riproducono un volantino promozionale, in cui si legge: *“tanto a poco dal 23 ottobre al 5 novembre”* nonché *“Il tuo supermercato di Corso Alpi a Bellusco/Via De Gasperi a Gorgonzola diventa ^{Org_8} ;*

. il doc. 23 appellante e il doc. 41 appellata riproducono un volantino promozionale, in cui si legge *“Grande festa ti aspettiamo giovedì 23 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 16,30 per festeggiare insieme l'arrivo del tuo nuovo ^{Org_8} con un brindisi, una fantastica torta e un omaggio per te. Inizia alla grande la tua raccolta punti Payback. Dal 23 ottobre al 5 novembre punti doppi sulla tua spesa”;*

. i doc. 24 e 25 appellante sono volantini promozionali, in cui gli sconti ulteriori, rispetto a quelli abituali, sono segnalati come *“follie d'apertura”* e sono esplicitamente limitati al periodo *“dal 23 ottobre al 5 novembre”;*

. il doc. 30 appellata ritrae un cartello pubblicitario, asseritamente affisso davanti al supermercato di Gorgonzola di ^{CP_3}, in cui si legge *“siamo freschi d'apertura - dal 23 ottobre al 5 novembre scopri la nuova convenienza”;*

. i doc. 39 e 40 appellata si riferiscono a un *“buono sconto 5 € con carta Payback a fronte di una spesa minima di 30 €”* e precisano *“promozione valida fino al 31.12.2014”;* da tale dicitura CORA ha erroneamente dedotto che la campagna promozionale sarebbe durata almeno fino al 31.12.2014; in realtà, ai fini dell'individuazione del periodo di durata della campagna promozionale rileva il periodo in cui i buoni sconto sono stati concessi alla clientela e non certo il giorno fino al quale tali buoni sconto, già acquisiti per una spesa fatta in precedenza, avrebbero potuto essere effettivamente incassati; pertanto da tale volantino non può certo desumersi che la campagna promozionale aveva avuto una durata fino al 31.12.2014;

. il doc. 39 appellata reca anche l'immagine di un *“buono spesa di € 10”*, di cui l'appellata ha contestato la genuinità e che pertanto, in assenza di prova in senso contrario, non può essere utilizzato, fermo restando che da tale porzione del doc. 39 non può trarsi alcuna indicazione, non essendo precisato in quale periodo e presso quale punto vendita tale buono spesa sia stato distribuito.

Per completezza si rileva che nessuno dei numerosi testi assunti ha riferito che, contrariamente a quello che risultava dai documenti sopra menzionati, la campagna promozionale era, in realtà, proseguita anche oltre le due settimane dall'apertura dei due nuovi supermercati.

Il teste *Tes_5* ha dichiarato che *“In quel periodo (NdR, ottobre – novembre 2014) c’è stata una promozione particolare sui punti vendita ex ^{Org-} che erano passati a *Parte_2* e, se ben ricordo, questo tipo di promozione era riservata solo agli ex ^{Org-}”*.

Il teste *Tes_8* ha dichiarato: *“Per quanto riguarda i prezzi diversi devo segnalare che i due punti di Gorgonzola e Bellusco erano in fase di lancio ed in tale fase iniziale vengono applicati da prassi, dei prezzi promozionali, come era stato fatto anche per i negozi dei *CP_4* nella loro fase di lancio”*

Anche il teste *Tes_6* ha confermato: *“E’ vero che *Parte_2* ha pubblicizzato le promozioni direttamente nei confronti della clientela, tramite SMS o volantini distribuiti in autonomia dal servizio *Parte_10*, escludendo da tali attività le Società del *CP_7* perché tale promozione era dedicata e riservata solo ai negozi ex ^{Org-} nel frattempo acquisiti da *Parte_2* così come si fa comunemente per le nuove aperture.”*

Anche il teste *Tes_7* (marito di una delle socie di almeno una delle affiliate) alla domanda: *“Vero che *Parte_10* nell’ottobre del 2014 ha pubblicizzato le promozioni direttamente nei confronti della clientela, tramite SMS o volantini distribuiti in autonomia dal servizio *Parte_10*, escludendo da tali attività le Società del Gruppo Penati *CP_1* *CP_1* e *CP_3*?”* si è limitato a confermare che le indicate attività promozionali era state svolte nel mese di ottobre 2014 (cioè nel mese di apertura di uno dei due supermercati in questione): *“ Confermo. Ci sono state iniziative pubblicitarie e promozionali di *Parte_2* da cui il *CP_7* è stato escluso ”*

Per concludere sul punto, risulta accertato che ^{Par} ha effettivamente condotto una campagna promozionale riguardante esclusivamente i nuovi punti vendita, aperti in gestione diretta a Bellusco e a Gorgonzola, ma tale campagna promozionale ha avuto la durata limitata di due settimane ed era finalizzata a pubblicizzare le nuove aperture, come era stato già fatto in occasione di precedenti nuove aperture anche di altri punti vendita ed in particolare proprio dei punti vendita del *CP_7*

La Corte ritiene che tale condotta costituisca una legittima deroga alla regola sopra individuata, secondo la quale, si ha esecuzione secondo buona fede del contratto di franchising senza esclusiva territoriale solo se l’affiliante riserva a tutti gli affiliati in concorrenza nella medesima area (quindi a maggior ragione anche a se stesso nel caso di gestione diretta) le medesime condizioni.

Infatti è evidente che l’affiliato nuovo entrato nella rete commerciale (o comunque il punto vendita a gestione diretta aperto *ex novo*), proprio per il fatto di doversi inserire in un tessuto commerciale preesistente, in cui sono attivi operatori già da tempo conosciuti dalla clientela, si trova in una condizione di evidente svantaggio rispetto ai concorrenti; pertanto non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto che l’affiliante riservi a tale nuovo punto vendita, per un periodo temporale ragionevolmente limitato, attività promozionali non concesse ai punti di vendita, già operativi da tempo.

b) In secondo luogo *CP_1* ha sostenuto che:

. dagli scontrini prodotti come doc. 29 risultava che nei due nuovi supermercati di ^{Par} ex ^{Org} venivano praticati prezzi più bassi rispetto a quelli da GS imposti a ^{CP_1} e agli altri supermercati del gruppo ^{CP_4}

. gli affiliati non potevano conoscere i prezzi applicati negli altri punti vendita (né in quelle gestiti direttamente da ^{Par} né in quelli gestiti da altri affiliati), mentre ^{Par} poteva conoscere i prezzi applicati dagli affiliati;

. gli affiliati erano obbligati ad acquistare da ^{Par} almeno il 60% della merce da loro rivenduta.

Dai contratti di franchising, dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte è risultato provato quanto segue.

- Con riguardo alla sussistenza di un regime di prezzi di rivendita imposti dal franchisor, l'art. 3.3.1 esclude che l'affiliato sia obbligato ad applicare i prezzi imposti dall'affiliante, dato che prevede solamente che “il ^{Parte_7} fornisce al ^{CP_9} il listino dei prezzi di vendita al consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutti di studi ed analisi di mercato”.

I testimoni hanno confermato che i supermercati del gruppo ^{CP_4} (come tutti gli altri affiliati) erano liberi di applicare alla merce, da loro rivenduta, i prezzi a loro discrezione, anche differenti da quelli consigliati quotidianamente da ^{Par} anche se di fatto venivano abitualmente applicati i prezzi consigliati, anche per difficoltà operative nell'apportarvi modificazioni.

Il teste ^{Tes_2} ha dichiarato: “I sistemi informatici del franchisee parlano direttamente con ^{Parte_2} ovvero le informazioni legate alle attività promozionali, in particolare il volantino, e alla carta fedeltà scendono, vengono inviati all'imprenditore attraverso i nostri sistemi. A quel punto l'imprenditore ha la facoltà di confermarle o di fare un diverso prezzo suo, a livello di rete, in particolare l'imprenditore si dota di un sistema c.d. Mini-catena che gli permette di modificare i prezzi in funzione dei suoi obiettivi di marginalità. Questo invio dei prezzi a tutti i punti vendita della rete è quello di consentire un allineamento, a favore del cliente, dei prezzi sulle attività promozionali, ferma restando l'autonomia dell'imprenditore di modificare il prezzo”, e alla domanda: “Vero che il sistema informatico aziendale ^{Parte_2} impediva al franchisee ogni modifica dei prezzi in entrata?” ha risposto: “^{Parte_2} invia l'informazione del prezzo che è imm modificabile e l'imprenditore può applicare oppure non applicare il prezzo inviato da ^{Parte_2} Non è vero che la modifica del prezzo da parte dell'imprenditore è teorica ma è concretamente eseguibile. Tutte queste circostanze accessorie che renderebbero difficoltoso lo scostamento dai prezzi di ^{Parte_2} non hanno alcuna rilevanza rispetto alla modifica dei prezzi di vendita, ma sono inerenti alla quantità di merce acquistata presso il franchisor ed anche il margine garantito è una conseguenza di quanto viene acquistato dal franchisee e non di quanto ed a quale prezzo vende le merci acquistate”

Il teste ^{Tes_3}, alla domanda “Vero che il sistema informatico aziendale ^{Parte_2} impediva al franchisee ogni modifica dei prezzi in entrata?” ha risposto “Non è vero”, quindi ha dichiarato: “Come detto i prezzi potevano essere modificati dal franchisee e tutte le attività ad esse inerenti ovviamente necessarie e conseguenti non possono considerarsi ostative di tali modificazioni”.

Il teste ^{Tes_7} (marito di una delle socie di almeno una delle società affiliate) dopo aver dichiarato, “Confermo, i prezzi in entrata, ovvero i prezzi di acquisto dei prodotti cioè i prezzi a cui la convenuta

acquistava le merci da **Parte_2** non erano modificabili dal franchisee”, ha dichiarato “Confermo per i prodotti acquistati da **Parte_2** i negozi del **CP_7** applicavano i prezzi di vendita al pubblico consigliati/imposti da **Par** e poi ha precisato “Confermo. Per tutti questi motivi la modifica (NdR dei prezzi indicati da **Parte_2** possibile in teoria non veniva mai realizzata in pratica”.

- Con riguardo all’obbligo imposto all’affiliata di acquistare da **Par** almeno il 60% della merce rivenduta (calcolato sulla base del fatturato dell’anno precedente), contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, deve escludersi che l’affiliata avesse tale obbligo, fermo restando che era certamente interesse della stessa acquistare la maggior parte della merce proprio da **Par** visti i premi attribuiti in connessione con l’ammontare di tale fatturato.

Infatti il contratto prevede “4.3.2 il franchisee si obbliga ad approvvigionarsi presso il franchisor di tutta la gamma dei prodotti previsti nel punto vendita per almeno il 60% del proprio fabbisogno, riferito a tutta la gamma dei prodotti previsti suddetti e calcolato sulla base del fatturato realizzato dal franchisee nell’anno precedente.”, ma al successivo punto 4.3.3 è prevista una deroga: “4.3.3. Peraltro il franchisee, in deroga a quanto sopra detto, proprio nel rispetto della sua autonomia imprenditoriale, avrà la facoltà di approvvigionarsi anche altrove di merci che rientrano nell’assortimento concordato, dandone preventiva comunicazione.”

A prescindere dalla non limpida chiarezza della disciplina contrattuale, tuttavia, dalla comunicazione del 10.3.2014 (quindi vigente nel momento in cui **CP_1** ha comunicato la risoluzione del contratto) di attribuzione dello sconto di fine anno al raggiungimento di *target* commerciali, calcolato in percentuale sul valore degli acquisti effettuati presso il franchisor (come da doc. 43 appellata), risulta (contrariamente a quanto pervicacemente ma erroneamente sostenuto dall’appellata), che lo sconto nella misura del 3,75% veniva attribuito senza alcuna condizione (quindi quale che fosse la quota di merce acquistata presso **Par** e che, nel caso in cui la percentuale di acquisto fosse stata almeno pari al 60,1%, la suddetta percentuale di sconto sarebbe stata maggiorata del 1% e così via nel caso di raggiungimento di quote di acquisti più alte, fermo restando che gli obiettivi di fedeltà si intendevano “di gruppo”; da questa comunicazione emerge quindi con chiarezza che, in fase di esecuzione del contratto di franchising, le parti, come peraltro poteva interpretarsi anche dalla lettura del contratto, concordavano sul fatto che su **CP_1** non gravava alcun obbligo di approvvigionamento presso **Par** per alcuna quota minima del suo fabbisogno.

- Con riguardo all’effettiva conoscibilità da parte dell’affiliata dei prezzi praticati dagli altri punti vendita, facenti parte della rete commerciale di **Par** dalle testimonianze assunte è risultato accertato che gli affiliati non avevano la possibilità di conoscere in tempo reale i prezzi praticati dagli altri punti vendita.

Il teste **Tes_2** ha dichiarato: “Confermo che i negozi del gruppo **CP_4** non potevano vedere i prezzi praticati dagli altri negozi ed in particolare dei due punti ex **Organizzazione_9** e Bellusco anche se, come regola generale, i negozi operanti sulla stessa piazza utilizzano un listino comune quindi l’invio dei prezzi consigliati da parte di **Parte_2** è uguale per tutti i punti vendita della stessa piazza ciò perché non si vuole penalizzare un punto vendita rispetto ad un altro sia che si tratti di una gestione diretta, sia che si tratti di un franchisee.”

Il teste *Tes_3* ha dichiarato: “Non è vera la prima parte. ^{Par} non poteva, tramite il sistema informatico, verificare i prezzi che i negozi del gruppo *CP_4* praticavano alla clientela. E' vero, invece, che i negozi di *CP_4* non avevano accesso a quelli degli altri punti vendita, ivi inclusi gli ex ^{Org_} ”.

Il teste *Tes_7* ha dichiarato: “ Confermo la circostanza. ^{Par} oteva vedere i prezzi che venivano applicati dal punto vendita in quanto presso ogni punto vendita è installato un computer che fa parte del sistema informatico *Parte_2* e che contiene i prezzi di acquisto e di vendita applicati dallo stesso punto vendita. A questo Computer io stesso ho più volte visto *Parte_2* accedere da remoto. Tramite tale accesso *Parte_2* poteva vedere in tempo reale, i prezzi che il punto vendita applicava alla clientela”.

- Con riguardo all’asserito ribasso dei prezzi praticato nei nuovi supermercati ^{Par} rispetto ai prezzi da questa consigliati alle affiliate del gruppo *CP_4* e quindi da queste praticati, gli scontrini prodotti (come doc. 29 appellata), in numero assai limitato e di difficilissima lettura, da un lato, non consentono certamente di ritenere provato neppure per i prodotti, dall’appellata individuati con prezzo ribassato, che tale ribasso non fosse episodico e relativo solo alla giornata in cui era stato rilevato, e, dall’altro lato, contengono per altri prodotti (evidenziati dall’appellante) prezzi più alti praticati nei nuovi supermercati ^{Par} rispetto a quelli praticati dalle affiliate del gruppo *CP_4*

In conclusione quindi, tenuto conto che, da un lato, i singoli affiliati ben potevano applicare alla merce rivenduta prezzi differenti da quelli consigliati e, dall’altro lato, non erano obbligati ad alcun approvvigionamento minimo presso ^{Par} non risulta accertato che i prezzi praticati dalle affiliate del gruppo *CP_4* siano stati sempre conformi ai prezzi consigliati da ^{Par} e sistematicamente superiori ai prezzi praticati dai nuovi supermercati ^{Par}

c) In terzo luogo l’appellata ha sostenuto che la sopra descritta condotta di ^{Par} ha determinato uno sviamento della sua clientela in favore dei due nuovi supermercati aperti da ^{Par} in Bellusco e in Gorgonzola.

Dalle testimonianze assunte è emerso, però, solamente, contrariamente a quanto contraddittoriamente affermato dal Tribunale (il quale, dopo aver affermato che la condotta tenuta da ^{Par} era contraria all’esecuzione di buona fede per il fatto di aver determinato, mediante sviamento della clientela, un pregiudizio economico per l’affiliata, ha escluso qualunque risarcimento in favore di *CP_1* proprio a causa della mancata prova del pregiudizio economico subito), che alcuni clienti si erano lamentati, per così dire vivacemente, della differenza dei prezzi, ma l’appellata non ha fornito alcuna prova né del fatto che i clienti storici del gruppo *CP_4* fossero definitivamente divenuti, in numero significativo, clienti dei nuovi punti vendita ^{Par} né che il gruppo *CP_4* avesse effettivamente sofferto, nel periodo controverso, una diminuzione di ricavi rispetto al periodo precedente; al riguardo, in particolare, avrebbero potuto essere prodotti almeno il registro degli incassi giornalieri, così da poter confrontare i ricavi del periodo controverso con quelli dell’analogo periodo dell’anno precedente ovvero con quelli dei mesi precedenti; in tal modo sarebbe stato possibile valutare se l’azione promozionale di ^{Par} in favore dei supermercati di nuova apertura di Bellusco e di Gorgonzola, ovvero, la, comunque non provata, politica di ribasso dei prezzi in tali nuovi supermercati, avesse effettivamente causato il lamentato pregiudizio economico ai punti vendita già esistenti nelle medesime località del gruppo *CP_4*

In conclusione quindi:

. risulta accertato che la campagna promozionale riservata ai supermercati gestiti direttamente da ^{Par} in Bellusco e in Gorgonzola e della durata limitata a due settimane, che certamente dovevano ritenersi concorrenti anche dell'odierna appellata (^{Controparte_1} , in quanto questa era parte del medesimo gruppo sociale, che gestiva due supermercati nelle medesime località di Bellusco e Gorgonzola, era giustificata dalla legittima esigenza di “lanciare” i due punti vendita di nuova apertura, così come era accaduto in precedenza per altri punti vendita in occasione della loro apertura;

. non risulta invece accertato né che nei due nuovi supermercati ^{Par} sia stata praticata sistematicamente una politica di prezzi ribassati, rispetto a quelli consigliati da ^{Par} alle affiliate e da queste, a loro dire, scrupolosamente applicati né che queste ultime, dopo l'apertura dei due nuovi supermercati ^{Par} abbiano subito una concreta diminuzione dei ricavi giornalieri derivanti dalle vendite.

Pertanto la Corte ritiene che, nel momento in cui ^{CP_1} ha comunicato che riteneva risolto il contratto di franchising in corso, in realtà nessun inadempimento era imputabile a ^{Par} il conseguente comportamento di ^{CP_1}, che, a decorrere dal 16.1.2015, ha cessato di adempiere a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai contratti di franchising e, a decorrere dal 23.1.2015, ha iniziato ad operare con l'insegna di una rete commerciale (^{Org_5}), concorrente di ^{Par} (in particolare, come rilevato dall'appellante risultano, tra gli altri, violati gli art. 4.1.1 dei contratti - obbligo di utilizzare il marchio in modo diligente, solerte e scrupoloso, 4.1.3 - obbligo di non utilizzare insegne né di pubblicizzare marchi diversi da quelli della “ ^{Parte_3} insieme a”, 4.2.5 - obbligo di esporre segni distintivi e materiale pubblicitario secondo le indicazioni del franchisor, 4.2.7 - obbligo di attivare le operazioni promo – pubblicitarie concordate, 4.5 - obbligo di non esercitare alcuna attività produttiva o commerciale in concorrenza, 10.5 - divieto di stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione), costituisce un grave inadempimento, che giustifica la risoluzione dei due contratti di franchising, intercorrenti tra ^{CP_1} e ^{Par} richiesta da quest'ultima.

Seconda questione: sussistenza e entità dei danni lamentati da ^{Part}

Come conseguenza dell'inadempimento di ^{Pt_11} ha chiesto di condannare l'affiliata a risarcirle il danno subito, eventualmente liquidandone in via equitativa l'ammontare, ai sensi dell'art. 1126 c.c., indicando di aver comunque subito i seguenti danni:

1) Lucro cessante corrispondente al guadagno che ^{Par} avrebbe conseguito dalla vendita di merci a ^{CP_1} se i due rapporti contrattuali avessero proseguito il loro corso fino alla naturale scadenza (ossia per altri 33 mesi, sino al 30.9.2017), pari a € 1.175.803 (calcolato, come da doc. 30, sulla base della media mensile dei ricavi degli ultimi tre anni, che è stata moltiplicata per 33 mesi e quindi valorizzata per il 9,77%, cioè il margine lordo di guadagno sul ricavo, risultante dai bilanci di ^{Par} .

2) Lucro cessante corrispondente al mancato introito del prezzo del franchising a carico di ^{CP_1}, pari a € 3.000 annuo per ciascuno dei due contratti, relativi l'uno al supermercato di Agrate e l'altro al supermercato di Azzano S.Paolo e quindi corrispondente, per il periodo fino al 30.9.2017, a € 16.500.

3) Danno emergente, da liquidare in via equitativa, corrispondente al danno al prestigio commerciale di ^{Par} che risulta sminuito per il fatto che CP_1 è passato al concorrente marchio Org_5 .

4) Danno emergente, da liquidare in via equitativa, corrispondente al danno subito per lo sviamento della clientela dai supermercati a marchio ^{Par} gestiti da CP_1 a Agrate e Azzano al concorrente marchio Org_5 .

Opinione della Corte d'Appello

Innanzitutto si premette l'infondatezza della tesi sostenuta da CP_1 , secondo cui ^{Par} avrebbe semmai diritto esclusivamente alla penale prevista dal punto 16.5 del contratto di franchising, commisurata al 2% degli acquisti effettuati dal franchisee negli ultimi dodici mesi (quindi nella fattispecie in esame pari a € 87.379,02, cioè il 2% dell'ammontare del valore degli acquisti effettuati da CP_1 nel 2014, indicati da ^{Par} nella misura di € € 4.368.951).

La tesi è infondata in quanto tale misura del risarcimento del danno è prevista esclusivamente per il caso di violazione del diritto di prelazione, disciplinato dal punto 16 del contratto, spettante al franchisor nel caso di trasferimento a terzi da parte del franchisee del punto vendita ovvero delle quote sociali dello stesso.

La Corte d'appello, non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare del danno subito da ^{Par} ritiene di procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa tenendo in considerazione le circostanze di seguito esposte.

1) Con riguardo al danno esposto da ^{Par} sopra menzionato al n. 1), dai documenti prodotti da ^{Par} (i cui dati sono riassunti nel prospetto di cui al doc. 30 appellante) emerge che, nei tre anni precedenti la risoluzione del rapporto (cioè dal 2012 al 2014), CP_1 aveva acquistato merce da ^{Par} per un importo annuale medio pari a € 1.806.609 nel supermercato di Azzano S.Paolo e pari a € 2.625.556 nel supermercato di Agrate e quindi per un importo complessivo medio di € 4.432.165; pertanto la media mensile dei ricavi era stata pari a € 369.347 (pari a € 4.432.165 : 12); CP_1 non ha contestato la correttezza dell'entità dei suddetti ricavi, come detto, indicati da ^{Par} per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Dato che i contratti franchising in questione avevano scadenza al 30.9.2017 è presumibile che nel periodo dal 1.1.2015 al 30.9.2017, pari a 33 mesi, i ricavi procurati a ^{Par} da CP_1 sarebbero stati pari a € 12.188.451 (pari cioè alla media mensile di € 369.347 moltiplicata per il periodo di 33 mesi); da tale importo devono però essere detratti i ricavi effettivi relativi al mese di gennaio 2015 (atteso che CP_1 ha dichiarato la risoluzione a decorrere dal 16.1.2015), indicati da ^{Par} nella somma complessiva di € 149.513 (di cui € 59.541 per il supermercato di Azzano ed € 89.972 per il supermercato di Agrate); pertanto il ricavo complessivo non conseguito da ^{Par} a causa della risoluzione anticipata del rapporto attuata da CP_1 ammonta a € 12.038.938.

La Corte ha già accertato che a carico di CP_1 non vi era alcun obbligo di effettuare gli acquisti presso ^{Par} neppure per una soglia minima, ma è presumibile che, qualora il rapporto fosse proseguito regolarmente fino alla sua scadenza naturale del 30.9.2017, CP_1 avrebbe continuato ad

approvvigionarsi presso ^{Par} anche dopo il 16.1.2015, per importi analoghi a quelli degli anni precedenti, anche perché in relazione a tali ricavi ^{Par} riconosceva all'affiliato significativi sconti di fine anno (tanto più che le variazioni di tali importi nei tre anni dal 2012 al 2014 sono veramente minime).

^{Par} ha inoltre sostenuto che il margine lordo di guadagno medio dalla stessa conseguito sui ricavi procurati da ^{CP_1} era pari al 9,77% e pertanto il suo mancato guadagno era pari a € 1.176.204 (pari al 9,77% di € 12.038.938).

^{CP_1}, come detto non ha contestato l'entità dei ricavi indicati da ^{Par} ma ha sostenuto che il margine del 9,77% da quella ^{Par} si riferisce unicamente alle vendite e agli acquisti di merci, trascurando del tutto invece altre importanti voci di costo quali le prestazioni di servizi su cui si basava il rapporto con i *franchisees* e i contributi a favore dei *franchisees*.

2) Con riguardo al danno esposto da ^{Par} sopra menzionato al n. 2), dai contratti franchising risulta che ^{CP_1} era obbligata a pagare il corrispettivo annuo di € 3.000 (quindi pari € 250 mensile) per ciascuno dei due supermercati gestiti per usufruire di tutti i servizi connessi all'utilizzo del franchising “^{Par} insieme a”; pertanto nel periodo dal 16.1.2015 (data della risoluzione anticipata dei rapporti) al 30.9.2017 (data della scadenza naturale), pari a 32,5 mesi, ^{CP_1} sarebbe stata obbligata a pagare a ^{Par} la somma di € 16.250 (pari a € 250 x 32,5 x 2).

3) Con riguardo al danno esposto da ^{Par} sopra menzionato al n. 3, l'appellante ha sostenuto di aver subito un danno alla sua reputazione commerciale per il fatto che ^{CP_1} ha aderito alla rete commerciale concorrente ^{Org_5}, per di più esponendo pubblicamente l'annuncio “*lieto di servirvi sotto l'insegna* ^{Org_5}”, che avrebbe carattere denigratorio.

In realtà il fatto che un punto vendita cambi rete commerciale non può certamente essere considerato lesivo della reputazione della rete commerciale abbandonata né l'annuncio, a cui fa riferimento ^{Par} nella sua asetticità può ritenersi, in sé e per sé, denigratorio del suo buon nome commerciale.

4) Con riguardo al danno esposto da ^{Par} sopra menzionato al n. 4), l'appellante ha sostenuto che il fatto che i punti vendita del gruppo Penati abbiano illegittimamente concluso contratti di franchising con la rete commerciale concorrente di ^{Org_5} ha determinato uno sviamento della clientela, già acquisita, dalla rete ^{Par} alla rete ^{Org_5}.

Dell'effettiva sussistenza di tale sviamento non è però stata fornita alcuna prova, neppure indiziaria, tenuto conto peraltro che, almeno con riguardo alle piazze commerciali di Bellusco e di Gorgonzola, l'esistenza in tali località dei due nuovi supermercati ^{Par} consentiva alla clientela, che intendeva mantenere il legame con la rete ^{Par} di continuare a farlo, senza alcun particolare onere aggiuntivo; analogamente può dirsi anche per la clientela della piazza commerciale di Agrate, come già detto, distante meno di 10 km sia da Bellusco che da Gorgonzola, pur dovendo, in questo caso, sottostare la clientela ad un onere maggiore, ma sostanzialmente trascurabile.

In ogni caso si evidenzia che i contratti di franchising illegittimamente risolti da ^{CP_1} sarebbero comunque scaduti il 30.9.2017 e che pertanto da tale data la stessa ben avrebbe potuto non rinnovare

l'affiliazione, determinando così, in ogni caso, la perdita del tutto legittima per la rete ^{Par} della clientela fino a quel momento legata alla sua rete commerciale; ma per il periodo precedente dal 16.1.2015 (data dell'illegittima risoluzione dei contratti di franchising) al 30.9.2017 (data di scadenza naturale dei contratti e quindi data finale fino alla quale ^{Par} poteva vantare il diritto a non subire sviamento di clientela) il danno subito per tale motivo da ^{Par} risulta già interamente coperto dall'importo sopra indicato sub. 1) a titolo di lucro cessante.

In conclusione, tenuto conto delle considerazioni suddette, che porterebbero ad una determinazione del danno, subito da ^{Par} nella misura di € 1.192.454, ma tenuto altresì conto del fatto che, da un lato, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di una qualunque prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava ^{CP_1}, non può ritenersi certo che ^{CP_1} avrebbe continuato ad acquistare merce da ^{Par} fino al 30.9.2017 nella stessa misura degli ultimi tre anni precedenti la risoluzione, e, dall'altro lato, del fatto che, come evidenziato dall'appellata, si deve anche considerare che, a fronte dei ricavi derivanti dalla vendita della merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi della stessa, ma anche tutti gli altri costi, anche generali, che sarebbero stati sopportati da ^{Par} qualora il rapporto di franchising con ^{CP_1} avesse continuato ad essere efficace, quali, a titolo d'esempio, i costi per i servizi in favore del franchisee previsti dal franchising, i costi per la movimentazione e la consegna della merce, i costi amministrativi inerenti il rapporto, gli eventuali premi attribuiti al franchisee.

In definitiva dunque pare equo determinare il danno subito da ^{Par} nella misura complessiva di € 1.000.000, liquidato in tale entità alla data della presente sentenza e comprensivo anche degli interessi spettanti già maturati.

^{CP_1} in quanto soccombente, è obbligata a rifondere le spese di lite sostenute da ^{Parte_1} in entrambi i gradi del giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 520.000 a € 1.000.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, per il giudizio d'appello, dato che nel presente giudizio tale fase non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 7693/2019, così dispone:

1) Dichiara risolti i contratti di franchising stipulati tra ^{Controparte_1} e ^{Parte_1} il 1.10.2007 per inadempimento di non scarsa importanza di ^{Controparte_1}

2) Condanna ^{CP_1} nella sua qualità di incorporante di ^{Controparte_1} a risarcire il danno subito da ^{Par} liquidato in complessivi € 1.000.000, con interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

3) Condanna *CP_1* nella sua qualità di incorporante di *Controparte_1* a rifondere le spese di lite sostenute da *Parte_1* che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 27.804 e, per il presente giudizio, in complessivi € 17.628, oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano il 4.2.2021

Il Consigliere est Massimo Meroni

Il Presidente Carla Romana Raineri